

1500858-60.2021.8.26.0441

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... contribui para a propagação do tráfico de drogas, na função popularmente conhecida como "olheiro". A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a consumação desse delito na situação em que o autor, como olheiro do tráfico, "valia-se de um apito e de uma arma de fogo [...], sendo certo que recebia semanalmente determinada quantia dos líderes da quadrilha pelas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

2ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Centro - CEP 11750-000, Fone: (13) 3455-3629, Peruíbe-SP - E-mail: peruibe2@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Reclamação:

1500858-60.2021.8.26.0441 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Data da Audiência:

03/03/2022 às 16:00h

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEN KAUAN DA SILVA CUNHA e outro

Vistos.

WESLEN KAUAN DA SILVA CUNHA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c o artigo 61, II, alínea "j" do Código Penal e ADRIANO DOS SANTOS CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 29, caput, e artigo 61, II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, no dia 05 de outubro de 2021, por volta das 17h10min, na Rua Marília, nº 700, Caraguava, local conhecido como "biqueira 26", nesta cidade e Comarca de Peruíbe/SP, em unidade de desígnios e comunhão de propósitos, traziam consigo e vendiam, para fins de tráfico e sem autorização, drogas consistentes em 02 microtubos de cocaína, com peso bruto de 11,9 gramas; 10 porções de skunk, com peso bruto de 13,57 gramas e 27 porções de maconha, com peso bruto de 57,18 gramas, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da pandemia da Covid-19.

Os réus foram presos em flagrante delito; suas prisões em flagrante foram convertidas em preventiva (fls. 88/90).

Os acusados foram regularmente citados e notificados (fls. 256 e 259), e apresentaram defesa preliminar (fls. 148/150), recebida a denúncia (fls. 163/164).

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de três testemunhas, tendo sido os réus interrogados.

Manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação dos acusados, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição por falta de provas; subsidiariamente, a fixação de penas no mínimo, atenuadas por confissão.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta parcial acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a materialidade, pela confluência de todas as elementares do delito do artigo 33 da Lei de Drogas, que se configurou consumado, em relação ao réu Weslen. Clara a tipicidade, não há dúvida razoável quanto à autoria. Correta a classificação dada à conduta.

Já quanto à conduta do réu Adriano, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, os fatos descritos na denúncia melhor se amoldam à figura típica do artigo 37 da Lei de Drogas, que consiste em colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da mesma lei, como se verá a seguir.

Eis a prova produzida:

O policial civil ANDERSON CARLOS LOMENZO BUONO relatou em Juízo que em diligências no bairro Caraguava a fim de combater a traficância, se dirigiram à "biqueira da 26" ou "Biqueira do Neinha". Neinha está preso mas ainda participa do tráfico. Foram em viatura descaracterizada ao local. A "biqueira" muda com frequência de local. Fizeram uma campana e avistaram o "olheiro" no local. O "olheiro" percebeu a presença da polícia e gritou "moiou". O "sacola" saiu em disparada e foi perseguido e detido pelo policial Roberto. Dentro da sacola havia maconha, "skank" e cocaína. Deteve o campana. Já o conhecia.

O policial civil ROBERTO PINHEIRO descreveu em Juízo que o local dos fatos é conhecido como biqueira da 26, bastante conhecido pela traficância. Foram até o local em viatura descaracterizada. Na chegada, avistaram o campana, o Adriano, que está com máscara na audiência. Ele estava na esquina orientando os usuários e alertando o traficante, em caso de presença da polícia. Depois, avistaram o Weslei com a sacola na mão servindo a um usuário. Ele notou a chegada dos policiais e empreendeu fuga. Conseguiu alcança-lo. Na sacola que ele tinha em mãos encontraram skank, maconha, cocaína e uma quantia em dinheiro. Os demais policiais pegaram o campana. O Weslei admitiu a traficância e disse que estava em necessidade financeira. O Adriano admitiu a campana e disse que recebia cerca de R\$ 30,00 por dia. O Adriano orientava os usuários e usava termos como "tá suave" e "moiou". As demais pessoas que estavam no local correram. Não conseguem abordar todos, então focam no traficante e no "olheiro". Conhecia os réus, já os havia abordado antes. Era comum ver o Adriano na campana.

O policial civil IVANA CAROLINE DA SILVA ROCHA descreveu em Juízo que participou da ocorrência. O local é conhecido como "biqueira da 26", que tem estrutura forte e estabelecida. Funciona 24 horas por dia e há diversos traficantes e olheiros que atuam de forma alternada. Fizeram uma campana e observaram uma pessoa orientando os usuários e indicando onde estava sendo feita a venda dos entorpecentes. Seguiram acompanhando e viram um indivíduo posicionado com uma sacola em mãos. Quando tentaram a abordagem, o "sacola" empreendeu fuga e foi alcançado pelo policial Roberto. A depoente e o policial Anderson abordaram o "olheiro" que estava na esquina. Detiveram os dois. Adriano era o "olheiro" e Weslei era o "sacola". O Adriano disse que é usuário de crack e era remunerado com R\$ 30,00 por dia. Weslei

também confessou informalmente, disse que tinha começado naquele dia ou no anterior, e que estava traficando pois passava dificuldades em casa. Na sacola havia cocaína, maconha e skank. A droga já estava embalada em porções individualizadas. Não lembra de tê-los abordado antes.

O réu Adriano informou em juízo que trabalha como campana para sustentar seu vício. É usuário de crack. Ganhava R\$ 30,00 por dia. Gastava tudo em droga. Com R\$ 30,00 pegava seis "pedras" de crack. Fica no local e avisa quando a polícia chega, grita "Moizou". É usuário de crack há muito tempo. Não correu. Estava "louco" de droga. Quem estava vendendo no local era André, não era Weslen.

O réu Weslen afirmou, em juízo, que não é vendedor de drogas. Foi comprar drogas. Chegando no local, como já tinha usado bastante e seu dinheiro tinha acabado, eles pediram para pegar as drogas e levar para outro lugar. Não tentou fugir. Não sabia a quantidade de drogas que tinha. As drogas estavam em sua cintura. Estava de bicicleta e ia levar as drogas ao traficante André. Ia receber em drogas por esse serviço. Já tinha usado drogas e queria mais. Está arrependido. Assume que errou, mas não estava traficando. Quer parar de usar droga. Não tem mais vontade de usar. Sempre foi trabalhador.

A confissão prestada em Juízo por ambos os réus, de espontaneidade inquestionável, não destoa do mais da prova produzida, que demonstra à sociedade a realidade da hipótese acusatória.

É certo que o depoimento de policiais deve ser apreciado com cautela pelo magistrado. A nobre função por eles exercida, merecedora de todo o respeito e consideração, envolve diretamente a repressão da criminalidade e, portanto, está em constante tensão com direitos constitucionais, ao mesmo tempo em que busca garanti-los. Disso decorre uma natural propensão de agentes de segurança a justificar a conduta que adotaram no exercício de suas dignas atribuições, ratificando-a em juízo, o que pode resultar na tendência de atribuir ao réu a prática da ação ilícita objeto de apuração. Isso, contudo e evidentemente, não obsta o depoimento de policiais; apenas suscita cuidado em sua valoração.

A esse respeito, é a lição doutrinária:

"É de bom senso e cautela que o magistrado dê valor relativo ao depoimento, pois a autoridade policial, naturalmente, vincula-se ao que produziu investigando o delito, podendo não ter a isenção indispensável para narrar os fatos, sem uma forte dose de interpretação. Outros policiais também podem ser arrolados como testemunhas, o que, como regra, ocorre com os realizadores da prisão em flagrante. Nesse caso, podem narrar importantes fatos, embora não deva o juiz olvidar poderem eles estar emocionalmente vinculados à prisão efetivada, pretendendo validá-la e consolidar o efeito de suas atividades. Cabe, pois, especial atenção para a avaliação da prova e sua força como meio de prova totalmente isento" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Grupo GEN, 2021 - e-book). O C. Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar a respeito do valor probatório do depoimento de policiais:

"A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1.ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC 485.543 - SP, 5.ª T., rel. Felix Fischer, 21.05.2019, v.u.).

Nesse aspecto, ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem os fatos quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem.

As circunstâncias da prisão do réu e da apreensão da res foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais apresentaram relatos detalhados e convincentes, coincidentes e harmônicos entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial acerca do ocorrido. Coerentes e precisos, expostos de forma coesa e lógica, merecem credibilidade os depoimentos das testemunhas.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para que as testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar os réus.

Bem demonstrado, assim, que o réu Adriano foi surpreendido quando fazia campana, atuando como "olheiro", a fim de alertar o vendedor das drogas acerca da presença da polícia.

Como se apurou nos autos, os policiais ouvidos foram unânimes em afirmar que Adriano estava fazendo "campana" e teria gritado "moiou" quando percebeu a presença dos policiais. Trata-se de conduta típica do denominado "olheiro", que tem por objetivo prestar informações aos traficantes acerca da presença policial, a fim de evitar abordagens inesperadas.

A esse respeito, convém reproduzir a lição doutrinária: "a colaboração que rende ensejo à incidência do art. 37 da Lei de Drogas é a que se opera por meio da prestação de informações, tal como ocorre quando o agente, exemplificativamente, contribui para a propagação do tráfico de drogas, na função popularmente conhecida como "olheiro". A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a consumação desse delito na situação em que o autor, como olheiro do tráfico, "valia-se de um apito e de uma arma de fogo [...], sendo certo que recebia semanalmente determinada quantia dos líderes da quadrilha pelas funções desempenhadas". É de ressaltar, contudo, que, a despeito de atuar como olheiro, nos casos em que o sujeito vier a exercer a vigilância do ponto do tráfico, será possível a sua responsabilização pelo crime definido no art. 33, caput, se ficar evidenciada a guarda da própria droga. Também incorre no delito em análise o agente que, devidamente acordado com os chefes do tráfico, atua para avisá-los sobre eventuais ações policiais, por vezes soltando foguetes e disparando outros sinais sonoros" (Masson, Cleber. Lei de Drogas - Aspectos Penais e Processuais. (2nd edição). Grupo GEN, 2021 - e-book).

Por sua vez, o réu Weslen foi surpreendido quando tinha consigo as drogas, destinadas ao fim de mercancia.

Embora alegue em sua defesa que não estava vendendo, mas apenas transportando as drogas, fato é que isso em nada afasta a ocorrência do delito, pois a conduta de transportar se amolda igualmente à figura típica do artigo 33 da Lei de Drogas.

O conjunto probatório é seguro e convincente, formado pelos relatos coincidentes das testemunhas, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

As drogas vêm descritas no auto de apreensão de fls. 15/16, estando a materialidade do delito demonstrada pelo auto de constatação de fls. 17/18 e pelo laudo químico toxicológico de fls. 242/244, em que apontada a presença dos princípios ativos característicos nas substâncias apreendidas.

A quantidade (49,8 gramas), a variedade (cocaína, maconha e skank) e o modo de disposição das drogas (ependorf e pequenas porções) e as circunstâncias em que apreendidas, quando postados os réus em ponto estabelecido de tráfico, não se mostram compatíveis com destinação outra que não o comércio ilícito, de que claramente proveniente o dinheiro apreendido (R\$ 85,00).

A condenação dos acusados é, pois, de rigor. Passo à dosagem das penas que lhes serão impostas.

Ao delito descrito pelo caput do artigo 33 da Lei 11.343/06, praticado pelo réu Weslen, são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal e pelo artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão 500 (quinhentos) dias-multa, pois a culpabilidade do agente e os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Não há elementos que denotem conduta social ou personalidade acentuadamente negativas; os antecedentes do réu serão valorados a seguir. A quantidade de drogas não é substancial, não recomendando incremento da pena.

Embora o réu seja reincidente, como comprova a certidão de fls. 75/77, igualmente presente a atenuante genérica da confissão, mantenho a pena no patamar fixado na primeira fase, compensando as circunstâncias.

Não atua a agravante do artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, porque a situação de pandemia em nada influenciou a prática do delito e tampouco foi por ele impactada.

Não incide a causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º ao artigo 33, concebida para adequação da pena a conduta apenas eventual e de pequeno vulto, dada a reincidência do acusado, de sorte que torno definitivas as penas fixadas.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime fechado, único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, mesmo à vista do quantum fixado, considerada a reincidência específica do acusado.

Ao delito descrito pelo caput do artigo 37 da Lei 11.343/06, praticado pelo réu Adriano, são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal e pelo artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, pois a culpabilidade do agente e os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Não há elementos que denotem conduta social ou personalidade acentuadamente negativas; os antecedentes do réu serão valorados a seguir. A quantidade de drogas não é substancial, não recomendando incremento da pena.

Embora o réu seja reincidente, como comprova a certidão de fls. 78/79, igualmente presente a atenuante genérica da confissão, mantenho a pena no patamar fixado na primeira fase, compensando as circunstâncias.

Não atua a agravante do artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, porque a situação de pandemia em nada influenciou a prática do delito e tampouco foi por ele impactada.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitivas as penas fixadas.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime fechado, único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, mesmo à vista do quantum fixado, considerada a reincidência específica do acusado.

Deixo de aplicar de imediato a detração, porque a matéria é de competência do Juízo

das Execuções, à míngua de elementos bastantes nos autos para a aferição dos critérios de progressão.

A propósito: "HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c art.14, inciso II, ambos do Código Penal. Pedido de alteração do regime inicial fechado para o aberto e detração de pena. Sucedâneo de recurso próprio (apelação criminal). Por seu turno, a análise da detração de pena é competência do Juízo das Execuções. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o "habeas corpus" para rever sentença condenatória, pois a questão suscitada demanda exame de fatos e provas processuais. ORDEM NÃO CONHECIDA". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2226711-68.2016.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016)

A esse respeito, do julgado acima mencionado extrai-se o seguinte trecho, da lavra do i. Des. Camargo Aranha Filho: "(...) Em relação ao pedido de detração de pena, cumpre observar que, de fato, a lei n. 12.736/12 estabeleceu nova disposição ao artigo 387, do Código de Processo Penal, para que o instituto da detração pudesse ser considerado pelo juízo do conhecimento no momento da prolação da sentença condenatória, evitando-se, conforme se extrai da Exposição de Motivos da novel legislação, circunstância em que o sentenciado tenha que aguardar a decisão do juiz da execução penal permanecendo nesta espera em regime mais gravoso ao que pela lei faz jus. Entretanto, perfilhamos o entendimento de que a inovação legislativa, ao ampliar o alcance da jurisdição do juízo do conhecimento, permitindo-lhe operar a detração já na sentença condenatória, termina por confundir dois institutos penais distintos: a detração, em si, e o regime de cumprimento de pena, confusão que viola os princípios de individualização da pena, do juiz natural e da isonomia; todos de índole fundamental previstos no artigo 5º, caput, e incisos XLVI e LIII, da Constituição da República. O período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal".

Ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da pena corporal, não se afigurando a medida socialmente recomendável (art. 44, inciso III, e § 3º, CP), visto que ambos os réus são reincidentes específicos.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar os réus WESLEN KAUAN DA SILVA CUNHA por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, e ADRIANO DOS SANTOS CRUZ por infração ao artigo 37, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 300 dias-multa, no valor unitário mínimo.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, devendo ser prontamente

implantado em estabelecimento penal condizente ao regime ora fixado.

Autorizo que se proceda à destruição das drogas apreendidas. Oficie-se desde logo para tanto.

Após o trânsito em julgado:

a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição;

b) expeça-se mandado de prisão e, verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento;

c) proceda-se à transferência do dinheiro apreendido ao Funad, decretado seu perdimento em favor da União;

d) não reclamada a restituição do aparelho celular apreendido em até 90 dias seguintes ao trânsito em julgado por quem comprove documentalmente regular aquisição, oficie-se para sua destruição;

e) comuniquem-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ);

f) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

Peruíbe, 03 de março de 2022.

CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO
Juiz Substituto